

1010367-82.2022.8.26.0006

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Luciana Mendes Simões Botelho

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... temática:

"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. ROUBO DE CELULAR CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. Consumidor vítima de roubo de celular. Terceiro que logrou, via ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

4ª Vara Cível

Rua Dr. João Ribeiro, 433, São Paulo - SP - cep 03634-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1010367-82.2022.8.26.0006 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010367-82.2022.8.26.0006

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Raquel Jacobs de Lima

Requerido:

Banco Bradesco S.A. e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho

Vistos.

RAQUEL JACOBS DE LIMA, qualificado nos autos, ajuizou ação declaratória de débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela de urgência contra BANCO BRADESCO S/A e PIC PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A., também qualificados. Aduz, em síntese, que em 10/11/2021, por volta das 20h, teve seu celular roubado. Dos fatos lavrou Boletim de Ocorrência eletrônico. Tentou sem sucesso acessar suas contas bancárias, mas as rés enviavam código para o smartphone roubado. Em 12 de novembro, compareceu à agência bancária e constatou a realização de diversas transações bancárias pelos aplicativos, dentre as quais um empréstimo bancário no valor de R\$ 9.663,80 e transferências bancárias que totalizam a importância de R\$ 11.246,30. Administrativamente, as rés negaram responsabilidade pelos fatos. Diz que seu nome encontra-se negativado e o score sensivelmente reduzido. Dos fatos lhe decorreram danos morais estimados em R\$ 36.000,00. Discorreu sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Pugnou pela concessão de tutela de urgência e inversão do ônus da prova. Nos termos dos pedidos, requer: "(i) declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito

indevido imputado à Autora referente ao empréstimo no valor de R\$ 9.663,80 (nove mil e seiscentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) e transferências bancárias, perfazendo no total a quantia de R\$ 11.243,30 (onze mil e duzentos e quarenta e três reais e trinta centavos), bem como taxas, juros e correções cobradas desde a fraude praticada em sua conta Corrente; (ii) Condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à Autora ao valor não inferior a R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) ou em quantia a ser arbitrada por Vossa Excelência, cujo valor deve ser corrigido a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ8), com a incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ9); (iii) Condenar as Rés ao pagamento das honorários advocatícios e custas processuais, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC (fls. 19-20, grifamos)."

Deferida a tutela de urgência, para exclusão do nome da autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (fls. 59/60).

As requeridas foram regularmente citadas (fls. 66/67).

O Banco Bradesco S/A contestou o feito nas fls. 68/77, sustentando, em síntese, que as operações questionadas foram realizadas com o uso de cartão e senha de uso pessoal e intransferível. Apontou que a comunicação dos fatos à instituição financeira foi realizada tardiamente. A autora não cancelou os acessos pelo Phone Fácil, tampouco utilizou dos meios disponíveis para o bloqueio dos dados. As transferências foram realizadas para conta de mesma titularidade da autora. Não houve falha na prestação de serviços. Ausentes os pressupostos do dever de indenizar. Teceu considerações sobre os critérios de fixação dos danos morais. Impugnou o pedido de inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos. Juntou os documentos de fls. 78/109.

A corré Picpay contestou o feito nas fls. 110/145, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, discorreu sobre a natureza dos serviços prestados, consistentes em um serviço eletrônico de pagamentos, pelo qual os consumidores podem efetuar pagamentos com cartão de crédito, envio e recebimento de dinheiro, pagamento de boletos, emissão de cobranças, recarga de celular e cartões de transportes, bem como armazenar dinheiro em carteira virtual e utilizar o saldo da carteira virtual em mais de 5 (cinco) milhões de estabelecimentos cadastrados. Afirma inexistir responsabilidade pelas fraudes praticadas por criminosos antes da comunicação pelo usuário acerca do furto/roubo. Não praticou ato ilícito. Os fatos narrados foram praticados por terceiros mediante o acesso aos aplicativos do celular por eles roubado. O saldo existente na carteira virtual antes das transferências realizadas era de R\$ 1,23. Atribui culpa exclusiva da vítima e atos de terceiros como excludente de responsabilidade civil. Discorre sobre a segurança e proteção dos dados pelo sistema disponibilizado. As transações questionadas foram realizadas pelo aplicativo mobile instalado no aparelho de celular, mediante a inserção de senha ou biometria do titular. Não houve pedido de alteração de senha, tampouco irregularidade interna. Apontou que a comunicação dos fatos foi realizada tardiamente. A não comunicação imediata impediu a ré de evitar os prejuízos narrados na inicial. Não houve falha na prestação de serviços. Ausentes os pressupostos do dever de indenizar. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos. Juntou os documentos de fls. 146/225.

Réplicas dadas nas fls. 229/234 e 235/238.

As partes manifestaram desinteresse na dilação probatória e requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 242, 243 e 244).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Possível o pronto julgamento da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, haja vista ser desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Anote-se, por oportuno, o desinteresse das partes na dilação probatória.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva defendida pela corré Picpay, porque seu embasamento jurídico se confunde com a matéria de mérito propriamente dita, por envolver discussão sobre a existência ou não de sua responsabilidade nos fatos narrados pelo autor.

Ao mérito, pois.

O cerne da discussão cinge-se à existência de falha na prestação de serviços das rés, bem como de prejuízos morais e materiais indenizáveis à autora, decorrentes de transação financeira não autorizada (empréstimo de R\$ 9.663,80), transferida à carteira digital de titularidade da autora junto à corré PICPAY, por meio de aparelho celular objeto de roubo no dia 10/11/2021, crime do qual a autora foi vítima.

Ao contrário do que alegam as rés, aplicam-se à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora, diante do contexto fático em discussão, se enquadra perfeitamente na condição de consumidor dos serviços bancários ofertados pelas requeridas, a quem compete garantir a qualidade e segurança que deles legitimamente se espera.

Trata-se, pois, de evidente relação de consumo, e não de insumo. Bem por isso, incidem no caso em tela as disposições do referido diploma consumerista, dentre as quais aquela que prevê ao consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos", que abrange "a inversão do ônus da prova" a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8078/90).

No ponto, o pedido inicial decorre da alegada falha na prestação de serviços – especificamente no que toca ao dever de segurança – e, em tal situação, os fornecedores, no caso, as rés, só não respondem pelos danos se provarem que o defeito inexistiu ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Se não provada a hipótese excludente, torna-se o fornecedor objetivamente responsável pela reparação dos danos causados pelo defeito na prestação dos serviços, como consequência do risco da atividade desenvolvida.

É dos autos que a autora mantém conta digital para realização de operações financeiras perante a corré Bradesco (agência 478, conta 7451-9) e carteira digital junto à corré PICPAY, a qual é responsável pela administração desse serviço.

Diz a inicial que houve a realização de empréstimo no valor de R\$ 9.663,80, junto à conta corrente 7451-9, do qual a autora é titular junto ao Banco Bradesco e os valores foram transferidos à carteira digital mantida pela corré, mantida na mesma instituição ré, em tese, com a utilização do celular dela roubado no dia 10/11/2021.

Na posse do referido aparelho celular roubado, os criminosos conseguiram fazer transferências da referida conta, que é protegida por senha.

De acordo com a autora, os fatos foram comunicados às rés, que se negaram a ressarcir a requerente o valor transferido indevidamente.

De lado outro, as rés sustentam, em síntese, culpa exclusiva da vítima e de

terceiros e que as transações foram realizadas com uso de dados pessoais, senha pessoal ou biometria, remetendo-se às cláusulas do termo de adesão ao serviço. Além disso, alegam que a autora apenas comunicou o ato ilícito dois dias depois de sua ocorrência, quando as operações já tinham sido efetivadas, inexistindo a possibilidade de realizar estornos da conta de destino, a qual também pertence à autora.

A prova coligida aos autos aponta para a ocorrência de defeito consistente em falha de segurança nos serviços disponibilizados pelas rés à autora a ensejar-lhes responsabilidade civil objetiva quanto aos danos postulados no pleito inaugural.

Com efeito, o documento de fls. 36/37, que instruiu a inicial, sinaliza que o empréstimo no valor de R\$ 9.663,80 questionado pela autora, foi feito no dia 11/11/2021, o qual argumenta o réu Banco Bradesco ser legítimo e insuscetível de estorno ou devolução.

Entretanto, além do valor transferido ser vultoso, a transação atacada foi realizada para carteira digital de titularidade da autora em várias operações de transferência (TEDs eletrônicos).

À toda evidência, a forma em que foram realizadas as transferências sinaliza pela suspeição das operações que fogem do perfil da consumidora, conforme demonstram os extratos bancários acostados nas fls. 107/109 pelo corréu Banco Bradesco S/A.

Sequer houve a apresentação, pelas rés, do processo para apuração da regularidade das transações.

Como cediço, a praxe neste tipo de conduta criminosa é justamente auferir o máximo possível de ganho financeiro da vítima no menor tempo após a prática do delito, vez que as instituições financeiras com as quais aquela mantém relacionamento serão evidentemente avisadas, resultando na inutilidade das informações de acesso bancário em poder dos criminosos.

Demais disso, as rés não demonstraram minimamente que o mesmo tipo de operação, com valores e horários assemelhados, eram comumente realizados pela autora.

Resulta inequívoco, pois, o acesso indevido aos dados bancários da demandante, via aplicativo em aparelho celular, sem que qualquer fornecimento espontâneo de senha e número da conta tenha sido por ela feito.

Aliás, sequer esclareceram as rés quais medidas de segurança utilizam para evitar a ocorrência de operações fraudulentas nos serviços bancários que disponibilizam, em acréscimo à tradicional senha de acesso ou token, que, no contexto da tecnologia contemporânea, é, por si só, insuficiente para coibir a audácia criminosa cada vez maior (aplicativo com ferramenta de reconhecimento facial, digital, token, etc).

Logo, em se tratando de ato próprio determinante para a eclosão do evento danoso, a conduta da vítima ou de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal em questão e nem de afastar a responsabilidade das requeridas.

Nessa senda, de rigor reconhecer a inexigibilidade das transferências bancárias e do empréstimo realizados no dia 11/11/2021, este último no valor de R\$ 9.663,80, bem como das taxas, juros e correções decorrentes de tais operações.

Pondero que se o procedimento de utilização dos aplicativos para uso em aparelhos celulares (incluindo-se o modo pelo qual neles é permitido o acesso a serviços bancários) foi concebido e regulamentado pelas próprias rés, não existindo razão lógica, jurídica ou moral, para que estas não assumam os riscos do sistema.

O caso dos autos retrata nítido fortuito interno, fazendo incidir a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias".

A esse respeito, confirmam-se os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização - Prestação de serviços bancários - Operações de crédito e transferência indevida de numerário em conta corrente, por meio de aplicativo em aparelho de telefonia celular - Falha imputável ao Banco-réu, que responde objetivamente pelos prejuízos do autor - Ato ilícito e falha na prestação do serviço bancário - Restituição ao autor dos valores indevidamente retirados de sua conta e declaração de nulidade dos mútuos contraídos - Admissibilidade - Dano moral - Ocorrência - Desnecessidade de prova - Dano "in re ipsa" Indenização fixada em R\$ 5.000,00 - Valor mantido - Sentença mantida - Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor total da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação." (Apelação Cível nº 1000217-87.2019.8.26.0704, 20ª Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador ÁLVARO TORRES JÚNIOR, julgado em 04/05/2020);

"AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Irresignação do banco réu e recurso adesivo da autora - Roubo de celular que continha o aplicativo para movimentação da conta corrente - Constatada a existência de várias operações financeiras que não foram reconhecidas pela sua titular - Negativa de restituição ao fundamento de que houve validação com senha pessoal do aparelho móvel - Insubsistência - Comprovação de que essa foi, de fato, a conduta criminosa, tendo os meliantes alterado a senha do aparelho celular e logrado êxito em acessar o aplicativo do banco réu - Instituição financeira que não efetuou o devido controle da movimentação da conta corrente da cliente, e que permitiu operações que destoam do perfil da correntista sem as devidas cautelas - Nexo causal demonstrado - Falha na prestação de serviço - Devolução, entretanto, dos valores descontados da conta corrente da autora que devem ser feitos de forma simples e não em dobro - Inexistência de má-fé do requerido - Dano moral caracterizado - Valor da indenização fixado em R\$5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença parcialmente reformada - Recurso do banco réu não provido e recurso adesivo da autora parcialmente provido, com alteração da sucumbência." (Apelação Cível nº 1001600-07.2020.8.26.0562, 11ª Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador MARCO FÁBIO MORSELLLO, julgado em 04/11/2020).

Nessa senda, de rigor a declaração de inexigibilidade das transferências e empréstimo realizados no dia 11/11/2021, na conta corrente 7451-9, junto a agência 478 (Banco Bradesco), indicadas no extrato de fls. 36/37, bem como das eventuais taxas, juros e correção deles decorrentes, nos termos do pedido formulado na inicial.

Os danos morais pleiteados também procedem, os quais se caracterizam, no caso, pelo sofrimento e angústia experimentados pela autora com a prestação defeituosa dos serviços pelas rés, a consequente negativa do cancelamento do contrato de empréstimo obtido de forma fraudulenta a terceiro, os estornos dos valores indevidamente transferidos a terceiros da carteira digital mantida pela autora junto a corré PICPAY e o atendimento inadequado recebido para sua reclamação.

Sem dúvida, é o suficiente para a configuração do prejuízo moral reparável, não se tratando, à evidência, de mero incômodo ou dissabor. Não se olvida, ainda, que danos morais são caracterizados justamente pela privação ou diminuição de valores precípuos na vida das pessoas, como paz, tranquilidade de espírito, liberdade individual, integridade física e honra, entre outros.

Feitas tais considerações, passo à fixação do montante devido.

O arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial/pessoal das partes, suas atividades comerciais e, ainda, o valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades do caso concreto.

Considerando os elementos acima discriminados, entendo razoável a fixação do dano moral sofrido pela requerente na quantia de R\$ 5.000,00.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado envolvendo a mesma temática:

"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. ROUBO DE CELULAR CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. Consumidor vítima de roubo de celular. Terceiro que logrou, via aplicativo da instituição financeira, fazer indevida movimentação na conta corrente. Transferência entre contas no montante de R\$ 9.663,99. O autor não forneceu a senha a terceiros. A questão se localizava na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo, à senha da conta corrente do autor e sua movimentação. Nem se diga que à autora cabia também a comunicação ao banco réu para se evitar uso do aplicativo e acesso à conta corrente. O acesso ao aplicativo se dava por reconhecimento facial e em algum momento esta tecnologia falhou, visto que os criminosos tiveram acesso aos dados bancários do consumidor. Faltou segurança ao serviço bancário via aplicativo. Sua fragilidade viabilizou o indevido acesso dos fraudadores, porquanto o autor viu seu celular roubado sem que tivesse fornecido qualquer dado (senha ou número de conta corrente). E, o autor providenciou a desativação do Token (i-safe) vinculado ao aplicativo do banco réu. Todavia, ainda sim, após tomar essa medida de precaução, os criminosos lograram êxito no golpe. Na instrução do processo, constatou-se a inexistência de qualquer ato, culposos ou doloso, por parte do consumidor. Transações fugiam ao perfil do próprio autor. Antes mesmo das transações efetuadas, o agente criminoso requereu modificações na conta do autor que deveriam despertar no sistema de segurança do banco réu um alerta para se evitar a concretização das transações fraudulentas - Incidência da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do réu configurada. Danos materiais configurados. Indenização no valor de R\$ 9.663,99 mantida. Danos morais reconhecidos. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Indenização fixada em R\$ 5.000,00. Ação procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO". (Apelação Cível nº 1068955-28.2021.8.26.0100 - 17ª Câmara de Direito Privado; Rel: ALEXANDRE DAVID Malfatti - j. 28/6/2022 - grifei).

Pelo exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para o fim de: a) declarar a inexigibilidade das transferências e empréstimo realizados no dia 11/11/2021, na conta corrente 7451-9, junto a agência 478 (Banco Bradesco), indicadas no extrato de fls. 36/37, b) declarar a inexigibilidade de eventuais taxas, juros e correção deles decorrentes, nos termos do pedido inicial; c) condenar as rés, solidariamente, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros moratórios legais de 1% ao mês, contados da citação.

Em face da sucumbência, arcarão as rés, solidariamente, com o pagamento das custas

e despesas processuais, assim como com os honorários advocatícios da parte adversa, estes ora fixados em 15% sobre o valor da condenação atualizada, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

P.I.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA